

1524825-12.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... comum que usuários de drogas acabem se envolvendo com o tráfico para sustentar seus vícios.

Analizados, portanto, os aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524825-12.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524825-12.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Réu:

HENRICO SAMPAIO BONTEMPO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

HENRICO SAMPAIO BONTEMPO (RG. 38972319/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 34, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006; c.c. artigo 69 do Código Penal, porque, conforme consta da denúncia, no dia 21 de julho de 2022, por volta de 2h05min, no viaduto do Glicério, Sé, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, ao todo, 948,7g e 8,5ml de tetrahidrocannabinol (THC) e 5,3g de metilenodioximetanfetamina (MDMA), todas drogas, bem como objetos destinados ao embalo/fabrico/preparação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo apurou-se, policiais militares em patrulhamento pelo local, avistaram o réu conduzindo o veículo Fiat/Uno, de placas RNB0H80, na contramão e em alta velocidade, razão pela qual decidiram abordá-lo.

No bolso da blusa do denunciado, os policiais encontraram uma porção de haxixe e, no veículo, no banco traseiro, duas mochilas, em cujo interior havia diversos sacos e potes de maconha/haxixe, ampolas com óleo de cannabis, comprimidos de anfetamina, dois cigarros eletrônicos (possivelmente de maconha também, ante a inscrição THC, conforme foto de fls. 36), a quantia de R\$ 850,00 e uma balança de precisão, com finalidade de preparo/embalo das drogas, em sua maioria a granel.

O réu confessou informal e formalmente ter sido contratado (não forneceu dados de por quem) para o transporte das drogas de Pinheiros para Barueri, sendo que ganharia R\$ 500,00 para tanto.

Com ele estava a testemunha Bianca, sua namorada, que confirmou ter presenciado os policiais encontrando as duas mochilas, com drogas, balança e dinheiro, no veículo (fls. 13).

Em 01 de agosto de 2022, foi determinada a notificação do acusado e, na mesma oportunidade, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (fls. 80/82).

Em razão da prevenção ao contágio do Covid-19, a audiência de instrução e julgamento foi reservada na modalidade virtual (fls. 443/446).

O réu foi notificado (fls. 512) e apresentou defesa prévia (fls. 447/462). Em 30 de agosto de 2022, a denúncia foi recebida e, na mesma oportunidade, o novo pedido de revogação da prisão preventiva foi novamente indeferido (fls. 483/486). O réu foi citado (fls. 529).

Durante a fase de instrução, foram ouvidas três testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, a representante do Ministério Público postulou a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a fixação da pena no mínimo legal, regime mais brando, direito de recorrer em liberdade, dentre outras teses.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não havendo arguições preliminares, passo a conhecer o mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do réu HENRICO pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 34, caput, ambos da Lei n.º 11.343/2006; c.c. artigo 69 do Código Penal.

Ao final da instrução criminal, é de rigor o reconhecimento da PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação penal, a fim de condenar o réu somente pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/11.

Senão vejamos:

A materialidade do delito resultou provada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), fotografias das drogas, balança e valores apreendidos (fls. 33/38), laudo de constatação (fls. 27/32), laudo pericial do exame químico toxicológico definitivo (fls. 91/94), que constatou que os materiais apreendidos continham substâncias entorpecentes (THC e MDMA), inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

O mesmo pode ser dito em relação à autoria, apesar dos argumentos da nobre defesa. As circunstâncias que envolveram a flagrância delitiva, tais como: as quantidades e os tipos de drogas, as peculiaridades do flagrante, bem como a apreensão de petrechos destinados à preparação de drogas, não autorizam qualquer dúvida de que as substâncias apreendidas estavam na posse do réu e destinavam-se ao tráfico, nos termos do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, não sendo o caso de absolvição e tampouco de desclassificação para o delito previsto no artigo 28 do citado diploma legal.

Durante o interrogatório policial, o réu HENRICO disse que Bianca é sua namorada. Após saírem de um bar no bairro de Pinheiros, retornavam para Barueri, quando errou o caminho e ingressou na contra mão conduzindo o veículo Fiat/Uno, branco, placas RNB0H80 (veículo locado). Os policiais efetuaram a abordagem e acharam no banco traseiro do veículo que conduzia as duas mochilas. Dentro delas, havia drogas diversas que entregaria para o indivíduo conhecido por "FIO" (qualificação ignorada), morador da região de Cruz Preta-Barueri/SP. "FIO" contratou o interrogando pessoalmente para retirar uma mercadoria no bairro de Pinheiros com um indivíduo conhecido por "ZEQUINHA". Para fazer este "frete", ganharia R\$500,00 após entregar a mercadoria para "FIO". Em nenhum momento Bianca soube que dentro daquelas mochilas havia drogas. Somente o interrogando tinha conhecimento da existência de drogas nas mochilas. Ambos foram conduzidos para a delegacia. Não sabe informar quais tipos de drogas estavam na mochila. Porém, toda a droga fotografada estava nas mochilas. Tanto o interrogando quanto Bianca são

trabalhadores, trabalham vendendo perfumes e roupas para suprir suas subsistências. É usuário de maconha e consome para dormir. Foi expulso de casa pelos pais. Por desespero e precisando de dinheiro, aceitou o "frete" para ganhar R\$500,00. Nunca foi preso ou processado anteriormente. Não sabe informar a qualificação e ou endereços de "FIO" e "ZEQUINHA" (fls. 15).

Em Juízo, o réu HENRICO alegou trabalha em Barueri e foi até São Paulo com dois mil reais, para comprar peças para seu carro. Depois foram num restaurante japonês e encontraram uns amigos num bar. Conversou com este amigo sobre o que estava ocorrendo em sua vida. Ele pediu para levar uma mochila com drogas (maconha) por quinhentos reais para Barueri. No trajeto foi parado pela polícia. Era a primeira vez que fazia isso. O dinheiro foi apreendido na bolsa de sua namorada. Estava morando de favor na casa de sua namorada. Havia perdido o emprego e ficou com medo das contas que chegariam e acabou entrando nisso. Conheceu o "Zequinha" numa pista de skate em Pinheiros. Contou isso na delegacia. Se considera dependente químico, precisa de tratamento e está muito arrependido. Tinha conhecimento da ilicitude de sua conduta.

Decididamente, a confissão judicial torna incontroversa a autoria delitiva, mormente porque corroborada pelo restante da prova.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a confissão judicial realizada espontaneamente pelo réu, ainda que seja o único elemento incriminador, é o suficiente para autorizar o decreto condenatório, sobretudo quando inexistem elementos probatórios que comprovem sua falsidade ou algum vício de consentimento. Com efeito, tal confissão, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, possui valor absoluto, servindo como base condenatória. Ou seja, havendo confissão judicial, presumindo-se livremente feita, não demonstrada sua eventual falsidade por prova idônea, cujo ônus probatório incumbe ao confitente e sua defesa, só ela já basta e serve como alicerce para o decreto condenatório. Não bastasse a confissão judicial, esta foi amplamente confirmada pelo restante da prova, especialmente pelos seguros e convincentes depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação.

Os agentes da lei, ao contrário do firmado pela defesa, relataram os fatos de maneira convicta, restando claro que narraram apenas o que efetivamente ocorreu, descrevendo detalhadamente os fatos que presenciaram.

O relato dos policiais foi firme, coerente e detalhado.

A testemunha THIAGO, policial militar, reconheceu o réu e narrou que em patrulhamento de rotina quando depararam com o veículo em alta velocidade na contramão. Num primeiro momento não pensaram em abordar, mas ele demonstrou nervosismo. Resolveram abordar. Na revista pessoa, uma substância entorpecente. No banco traseiro muitas coisas, roupas, equipamento de ginástica e uma mochila com drogas, aparentemente maconha e outra que aparentava ser uma pasta, além de drogas sintéticas, oitocentos reais e balança de precisão. Ele foi indagado e disse que estava transportando a droga por quinhentos reais até Barueri. Ele falou que já havia feito isso mais de uma vez, mas não disse quantas. Ele disse que o wase o havia colocado em lugar errado. A namorada que estava junto disse que não tinha conhecimento dos fatos. Não sabe precisar a velocidade. Não lembra se havia resquícios de drogas na balança. Havia pacotes de drogas e pacotes abertos. O dinheiro não era miúdo. Não lembra quantas notas de vinte, cinquenta ou cem.

Da mesma forma, a testemunha KAIIO, policial militar, narrou que, em patrulhamento de rotina depararam com o carro dirigido pelo réu na contramão de direção. Na revista pessoal, encontraram haxixe. Na busca veicular localizaram duas mochilas com substância entorpecente, aparentemente maconha, comprimidos, ampolas e uma balança de precisão. Indagado a respeito, ele disse que tinha conhecimento que era droga e que fazia o transporte até Barueri por quinhentos reais. ele disse que já havia feito isso outras vezes. Ele estava com os olhos avermelhados. A garota que o acompanhava narrou não ter conhecimento dos fatos. Dentro da mochila havia cigarros eletrônicos. Com ele acharam a quantia de oitocentos e cinquenta reais, em notas de cinquenta e cem. Não recorda se havia resquícios de drogas na balança. Ele estava na contramão em alta velocidade. Não lembra onde estava o dinheiro. No carro havia roupas e calçados. Não lembra se ele tinha celular.

Verifico que os policiais narraram de maneira uníssona que, em patrulhamento de rotina, visualizaram o veículo conduzido pelo réu em alta velocidade e na contramão. Diante disso, efetuaram a abordagem e, no banco traseiro do carro, havia duas mochilas com drogas, uma balança, além de uma considerável quantia em dinheiro. Indagado, o réu confessou informal e formalmente que havia sido contratado para transportar os entorpecentes.

Anoto que, apesar dos argumentos da nobre defesa, a palavra dos policiais é digna de fé. Aliás, é impossível contestar-se, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, uma vez que o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se que diga a verdade, como qualquer testemunha.

Nesse sentido: "PROVA - Depoimento de Policiais - Valor: Inexiste motivo para que não se dê crédito às declarações de testemunhas, apenas por pertencentes aos quadros policiais, pois sua palavra, pelo contrário, há que se revestir da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral". (TACrimSP - Ap. nº 818.779/4 - 7ª Câmara - Rel. Luiz Ambra - J. 19.05.94 - RJDTACRIM 22/326).

Os policiais não teriam motivos para falsear a verdade no sentido de prejudicar o acusado, vez que sequer o conheciam até a data da ocorrência.

No mais, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os agentes policiais não estão proibidos de depor nos processos de cuja fase extrajudicial participaram.

Nota-se que o fato de o réu ser usuário de drogas não exclui a comprovação de que ele efetuava a mercancia ilícita, na modalidade "trazer consigo" e "transportar". Inclusive, é bastante comum que usuários de drogas acabem se envolvendo com o tráfico para sustentar seus vícios.

Analizados, portanto, os aspectos que devem necessariamente nortear a aferição do juízo em relação à mercancia ou não do entorpecente, depreende-se da prova dos autos, como medida de rigor, o reconhecimento da figura penal do tráfico de entorpecentes.

A prova é firme no sentido da responsabilidade criminal do réu. Senão vejamos:

O acusado foi surpreendido pela Polícia Militar enquanto trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, ao todo, 948,7g e 8,5ml de tetrahydrocannabinol (THC) e 5,3g de metilenodioximetanfetamina (MDMA), acondicionados em sacos e potes de maconha/haxixe, ampolas com óleo de cannabis, comprimidos de anfetamina, dois cigarros eletrônicos (possivelmente de maconha também, ante a inscrição THC, conforme foto de fls. 36), além da quantia de R\$ 850,00 e uma balança de precisão, com finalidade de preparo/embalagem das drogas, em sua maioria a granel.

Com efeito, a quantidade de drogas, somada à apreensão de petrechos destinados a pesar, individualizar, embalar e contabilizar as drogas, é suficiente para afastar a hipótese de que os entorpecentes eram destinados ao consumo pessoal do réu.

Logo, tem-se que todos os elementos de prova somados mostram-se meios hábeis e legítimos para sustentar a ocorrência da mercancia.

Sendo assim, apesar dos argumentos da defesa, dentro do contexto probatório, infere-se que a prova da acusação se mostrou firme e robusta para apontar o réu como traficante, não havendo dúvida sobre a posse e finalidade dos entorpecentes apreendidos pelos policiais.

Nunca é demais lembrar ser desnecessário, para a caracterização do tráfico ilícito, que o agente seja flagrado em pleno ato de venda, podendo a traficância ser determinada pela natureza e quantidade da droga apreendida, pelo local e condições em que se desenvolveu a ação.

Nesse sentido, o pacífico entendimento da jurisprudência: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Tipificação - Materialidade e autoria demonstradas - Quantidade, modo de acondicionamento e circunstâncias da prisão que revelam o intuito de tráfico - Prova - Validade do depoimento de policiais - Condenação mantida - Recursos não providos. (Apelação Criminal n. 271.172-3 - São Paulo - 4ª Câmara Criminal - Relator: Haroldo Luz - 19.10.99 - V. U.)".

Por fim, em consonância com o entendimento jurisprudencial, é forçosa a aplicação do princípio da consunção com relação ao delito previsto no artigo 34, caput, da Lei nº 11.343/06.

Isto porque o réu foi surpreendido com drogas e instrumentos destinados à

preparação de drogas no mesmo contexto fático e, por isso, deve responder apenas pelo delito previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Nesse sentido: “Ambos os preceitos buscariam proteger a saúde pública e tipificariam condutas que – no mesmo contexto fático, evidenciassem o intento de traficância do agente e a utilização dos aparelhos e insumos para essa mesma finalidade – poderiam ser consideradas meros atos preparatórios do delito de tráfico previsto no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006” (STJ, HC 109.708/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 23.6.2015, noticiado no Informativo 791).

“Responderá apenas pelo crime de tráfico de drogas – e não pelo mencionado crime em concurso com o de posse de objetos e maquinário para a fabricação de drogas, previsto no art. 34 da Lei 11.343/2006 – o agente que, além de preparar para venda certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência, mantiver, no mesmo local, uma balança de precisão e um alicate de unha utilizados na preparação das substâncias. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a saúde pública, ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida, ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no art. 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta” (STF, REsp 1.196.334/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª Turma, j. 19.09.2013, noticiado no Informativo 531).

Neste aspecto, anoto que a doutrina e a jurisprudência já destacaram que o delito de preparo é formal e antecede o crime de tráfico de drogas. É possível que ambas as condutas sejam autônomas, ou seja, quem prepara pode não fazer parte da organização que vende e entrega o entorpecente.

A diferença entre o artigo 33 e o artigo 34, ambos da Lei Especial, é que o artigo 34 se refere a preparação e o 33 a distribuição efetiva da droga ao consumidor.

No veículo do réu foram encontradas apenas a balança e as drogas. Nada foi apreendido ou encontrado que indique ser a balança um instrumento para a fabricação, produção, transformação ou preparo do entorpecente.

Neste caso, a balança pode ser considerada como objeto utilizado na extremidade final da atividade criminosa, a saber a disponibilização da droga já pronta ao consumo.

A condenação pelas duas condutas, desta feita, in casu, implicaria em dupla imputação em um mesmo delito

Por fim, anoto que estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. O réu é primário, a quantidade de drogas apreendidas não se mostrou elevada a ponto de presumir que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Neste ponto, saliento que é ônus do Ministério Público comprovar a presença da atividade criminosa e habitualidade da criminalidade na vítima do agente e, no caso dos autos, não foram produzidas provas nesse sentido.

Desta feita, não havendo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, em atenção ao artigo 42 da Lei de Drogas e ao artigo 59 do Código Penal, entendo que são desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, as circunstâncias do delito merecem maior grau de reprovabilidade, em razão da quantidade de drogas - 948,7g e 8,5ml de tetrahydrocannabinol (THC) e 5,3g de metilenodioximetanfetamina (MDMA) – que mostra-se apta a abastecer a mercancia ilícita e alcançar um número grande de usuários.

Com efeito, o crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável. A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do

crime e tipo do entorpecente apreendido. Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento. E mais: a conduta é prejudicial ao meio social.

Sopesadas, portanto, as condições delineadas pelo artigo 59 do Código Penal, notadamente consequência e circunstâncias do crime, é de rigor a pena acima do mínimo legal. Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do consumo de entorpecentes pelo País.

Assim, a pena será fixada 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. De outro lado, incide a atenuante da confissão, razão pela qual reduz a pena ao mínimo legal em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Na terceira fase, não há causas de aumento a serem aplicadas. De outro lado, atenta ao disposto no artigo 33, §4º, e artigo 42, ambos da Lei de Drogas, promovo a redução da pena no máximo de 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva para 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e, em consequência:

i) CONDENO o réu HENRICO SAMPAIO BONTEMPO (RG. 38972319/SP), qualificado nos autos, à pena de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, aplicando-lhe a causa de diminuição do artigo 33, §4.º, do citado diploma legal.

ii) ABSOLVO o réu HENRICO SAMPAIO BONTEMPO (RG. 38972319/SP), qualificado nos autos, das sanções previstas no artigo 34 da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Diante das condições judiciais desfavoráveis, deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos ou conceder o sursis penal, pois reputo insuficiente à reprimenda da conduta.

O cumprimento da pena privativa de liberdade deveria ser feito em regime prisional inicial SEMIABERTO, inexistindo qualquer inconstitucionalidade ou agressão ao princípio da individualização da pena, mormente porque permitida a progressão de regime, bem como porque desfavoráveis as circunstâncias judiciais. No entanto, considerando o tempo que já está detido em regime mais gravoso, fixo, desde já, o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, com direito de recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Oportunamente, expeça-se a competente guia, intimando-se o réu para audiência de regime aberto.

Quanto aos itens apreendidos, autorizo a incineração das drogas, o perdimento do valor em favor da União e a destruição da balança de precisão. Oficie-se.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA